Universität St.Gallen

Prüfungsbooklet Assessment

Rechtswissenschaft I B

Teil Schindler

Hinweise:

- **Die alten Prüfungen dienen als Lernhilfe.**
- **Die Musterlösungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.**
- **Die zitierten Stellen des Lehrbuchs oder die angegebenen Folien beziehen sich auf die zum Prüfungszeitpunkt aktuelle Auflage bzw. aktuelle Vorlesungsstruktur.**

Prüfung Assessment-Jahr – Sommer 2021

Teil Prof. Schindler

Name: | **Vorname:**

Muttersprache(n): Matrikel-Nr.:

Prüfungsfach: **Rechtswissenschaft I B (schriftliche Prüfung)**

2,170

Prüfungsteil: **Prof. Dr. B. Schindler (90 Minuten)**

Verantwortlich: Prof. Dr. S. G. Schmid

Bemerkungen:

Dieser Prüfungsteil umfasst **4 Aufgaben auf 14 Seiten** (inkl. diesem Deckblatt). Die Punkte verteilen sich folgendermassen auf die einzelnen Aufgaben:

1. Aufgabe	26 Punkte
2. Aufgabe	18 Punkte
3. Aufgabe	27 Punkte
4. Aufgabe	19 Punkte
Total	**90 Punkte**

Schreiben Sie direkt auf die Antwortblätter; sollten Sie Zusatzblätter benötigen, verwenden Sie bitte für jede Aufgabe ein separates Blatt.
Begründen Sie jede Antwort und nennen Sie die einschlägigen Rechtsnormen!

Aufgabe 1 — 26 Punkte

Der Sachverhalt ist frei erfunden!

Nero Niederer ist Nationalrat aus dem Kanton Zürich. In den Osterferien geht er mit seiner Frau und seiner siebenjährigen Tochter Tanja auf eine Wanderung im Baselbieter Kettenjura. Auf einem schmalen Wanderweg kreuzen die drei eine andere Familie, die einen Hund, genauer einen *American Pit Bull Terrier*, mit sich führt. Der Hund wird nicht an einer Leine geführt. Als er Tanja sieht, rast er sofort auf sie zu und beisst ihr fest in die Hand. Es dauert einige Momente, bis der Hundehalter Tanja befreien kann. Nero Niederer ist ausser sich vor Wut. Zum Glück hat seine Tochter Tanja nur eine geringfügige Verletzung davongetragen. Dennoch findet er es völlig unverantwortlich, dass im Kanton Basel-Landschaft Privatpersonen solche *Pit Bulls* halten dürfen, obwohl sie für Menschen – und insbesondere Kinder – nach Ansicht Niederers sehr gefährlich seien. Vor allem stört er sich auch daran, dass für solche Hunde im Kanton Basel-Landschaft nicht einmal eine generelle Leinen- und Maulkorbpflicht gilt.

Wieder zu Hause in Zürich angekommen, konsultiert Niederer die kantonalen Gesetzesgrundlagen in Zürich und stellt fest, dass die Zürcher Hundegesetzgebung Privatpersonen den Erwerb, die Zucht und die Haltung von *Pit Bulls* verbietet. Nationalrat Niederer will, dass ein solches Verbot in der ganzen Schweiz aufgrund eines Bundesgesetzes gilt. «Nur so können die Kinder vor diesen Biestern geschützt werden», ist sich Niederer sicher. In der nächsten Session reicht er einen entsprechenden Vorstoss im Nationalrat ein.

Frage 1: [12 Punkte]
Äussern Sie sich zunächst allgemein zur Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen. Beurteilen Sie anschliessend, ob Niederers Vorstoss mit der geltenden verfassungsmässigen Kompetenzordnung vereinbar wäre.

Nach dem Grundsatz der Einzelermächtigung des Bundes durch die Bundesverfassung (Art. 42 BV) (**1 Punkt**) ist der Bund nur zuständig, soweit die Bundesverfassung dem Bund eine Kompetenz ausdrücklich zuweist (**1 Punkt**). Ansonsten bleiben aufgrund ihrer subsidiären Generalkompetenz (Art. 3 BV) die Kantone zuständig (**1 Punkt**). Dies entspricht auch dem Gedanken der Subsidiarität, der in Art 5*a* BV festgehalten ist; er ist aber nur eine «politische Klugheitsregel» und vermag die realen Kompetenzen nicht zu beeinflussen.

Niederers Vorstoss und die damit verfolgte Absicht betreffen das Verhältnis zwischen Tieren und Menschen, genauer: den Schutz der Menschen vor gefährlichen Hunden (**1 Punkt**). Deshalb kann der Bund Niederers Vorhaben nicht auf Art. 80 BV (**0.5 Punkte**) stützen. Art. 80 BV begründet zwar eine Bundeskompetenz, bezieht sich aber

lediglich auf den Schutz der Tiere (vor ungerechtfertigten Verhaltensweisen des Menschen) – und nicht umgekehrt (**1 Punkt**). Dies ergibt sich insbesondere auch aus dem Wortlaut von Art. 80 Abs. 1 BV und der Marginalie, wo vom «Schutz der Tiere» bzw. vom «Tierschutz» die Rede ist (**0.5 Punkte**).

Genauer anzuschauen ist auch Art. 118 BV, der den Schutz der Gesundheit von Menschen betrifft (**0.5 Punkte**). Art. 118 Abs. 1 BV sieht eine fragmentarische Bundeskompetenz vor, die in den darauffolgenden Absätzen konkretisiert wird (**0.5 Punkte**). Art. 118 Abs. 2 BV weist dem Bund in den aufgezählten Bereichen des Gesundheitswesens Zuständigkeiten zu (**0.5 Punkte**) und begründet in diesem Ausmass umfassende, nachträglich derogatorische Bundeskompetenzen (**1 Punkt**). Allerdings handelt es sich nicht um eine umfassende Bundeskompetenz im Bereich der Gesundheitspolitik (**1 Punkt**); vielmehr verbleibt die Zuständigkeit ausserhalb der abschliessenden Aufzählung von Art. 118 Abs. 2 BV bei den Kantonen (**0.5 Punkte**). Der Schutz des Menschen vor gefährlichen Hunden lässt sich unter keinen der Bereiche in Art. 118 Abs. 2 BV subsumieren (**1 Punkt**).

Fazit: Niederers Vorhaben ist mit der geltenden verfassungsmässigen Kompetenzordnung unvereinbar (**1 Punkt**).

Frage 2: [8 Punkte]
Gehen Sie davon aus, dass der Bund gemäss der geltenden Bundesverfassung ***nicht kompetent ist, die von Niederer geforderten Vorschriften in einem Bundesgesetz zu erlassen***. Die Bundesversammlung will deshalb kein solches Bundesgesetz erlassen. Mit welchem Instrument könnten die Kantone trotzdem ein schweizweites, einheitliches Verbot von gefährlichen Hunden erreichen, ohne dabei die Bundesverfassung zu ändern? Was wären Nachteile eines solchen Vorgehens?

Die Kantone könnten miteinander eine interkantonale Vereinbarung abschliessen (**1 Punkt**), wie es Art. 48 Abs. 1 BV (**1 Punkt**) explizit festhält. Gerade die gemäss Sachverhalt angestrebte Vereinheitlichung eines kantonal geregelten Bereichs (hier: Schutz des Menschen vor gefährlichen Hunden) ist eines der Motive, weshalb die Kantone solche Vereinbarungen eingehen (**0.5 Punkte**).
Eine solche Vereinbarung wäre *rechtsetzender Natur* (**0.5 Punkte**), weil ihr mit dem Verbot gefährlicher Hunde eine generell-abstrakte Regelung zugrunde liegen würde (**0.5 Punkte**). Um ein (wie vom Sachverhalt gefordert) schweizweites Verbot zu erreichen, müsste der Einbezug möglichst aller Kantone angestrebt werden, womit es sich um einen *multilateralen Vertrag* handeln würde (**0.5 Punkte**). Allerdings hätte der Beitritt jedes Kantons zur Vereinbarung freiwillig zu erfolgen. Eine Verpflichtung zur Beteiligung oder eine Allgemeinverbindlicherklärung gemäss Art. 48*a* BV wäre nicht möglich (**0.5 Punkte**), da keiner der Bereiche in den Buchstaben a–i von Abs. 1 betroffen ist (**0.5 Punkte**).

Die Nachteile eines solchen Vorgehens hängen mit den Charakteristika interkantonaler Vereinbarungen zusammen. Insbesondere wäre die demokratische Mitsprache durch die Parlamente eingeschränkt, weil die inhaltliche Gestaltung des Vertrags typischerweise vor allem durch die Exekutive geschieht (**1 Punkt**). Da die Vereinbarung und auch Änderungen davon jeweils der Einstimmigkeit unter den Kantonen bedürfen, handelt es sich um ein schwerfälliges Rechtsetzungsinstrument (**1 Punkt**). Zudem gibt es keine gesamtschweizerische Plattform, auf der die interkantonalen Verträge veröffentlicht werden, was der Rechtssicherheit abträglich ist (**1 Punkt**).

Frage 3: [6 Punkte]
Gar nicht einverstanden mit Niederers Forderungen ist das Baselbieter Ständeratsmitglied Stephanie Stammbach. Ihr liegt eher der Schutz der Tiere vor den Menschen (und nicht umgekehrt) am Herzen. Immer wieder erfährt sie von Hunden, die bei ihren Haltern bzw. Halterinnen regelrecht verwahrlosen und nicht genügend spazieren geführt werden. Dabei bräuchten doch alle Hunde für eine gute Tiergesundheit unbedingt genügend Bewegung im Freien. Stammbach fragt Sie deshalb, ob es unter der geltenden verfassungsmässigen Kompetenzordnung möglich wäre, in einem Bundesgesetz schweizweit vorzusehen, dass alle von Privatpersonen gehaltenen Hunde täglich mindestens für eine Stunde spazieren geführt werden müssen?

Stammbach will mit ihrem Vorhaben Hunde vor aus ihrer Sicht ungenügender Haltung durch Menschen schützen (**1 Punkt**). Betroffen ist damit der Tierschutz gemäss Art. 80 BV (**1 Punkt**). Es handelt sich dabei um eine Bundeskompetenz (**1 Punkt**), wie sich aus dem Wortlaut («Der Bund *erlässt Vorschriften über*»)/der Stellung in der BV (3. Titel, 2. Kapitel) ergibt (**0.5 Punkte**). Vom Umfang her ist die Kompetenz *umfassend* (**1 Punkt**), was sich ebenfalls aus dem Wortlaut ergibt (**0.5 Punkte**). Die von Stammbach geforderte Pflicht liesse sich insbesondere auch unter Art. 80 Abs. 2 lit. a BV subsumieren (**1 Zusatzpunkt**).

[Hinweis: Wird die Bundeskompetenz betreffend Tierschutz bereits (und nur) bei Frage 1 näher qualifiziert, werden für diese Ausführungen hier Punkte angerechnet.]

Fazit: Stammbachs Vorstoss ist mit der geltenden verfassungsmässigen Kompetenzordnung vereinbar (**1 Punkt**).

Aufgabe 2 — 18 Punkte

Letztes Jahr begann sich das neue Coronavirus auf der Welt und auch in der Schweiz in Windeseile auszubreiten. Um die Pandemie einzudämmen, musste der Bundesrat immer wieder einschneidende Massnahmen anordnen. So auch am 18. Dezember 2020 angesichts der zweiten Welle. Die damals ergriffenen Massnahmen hatten gemäss Bundesrat zum Ziel, «die Fallzahlen deutlich und rasch zu senken, um die Menschen vor dem Virus zu schützen und die Gesundheitsversorgung sicherzustellen». Insbesondere entschied der Bundesrat an diesem Tag, Gastronomiebetriebe bis auf Weiteres zu schliessen. Die entsprechende Verordnungsbestimmung lautete:

Covid-19-Verordnung besondere Lage

Art. 5*a* **Besondere Bestimmungen für Restaurations-, Bar- und Clubbetriebe sowie für Diskotheken und Tanzlokale**

1 Der Betrieb von Restaurations-, Bar- und Clubbetrieben sowie von Diskotheken und Tanzlokalen ist verboten.

2 Das Verbot gilt nicht für folgende Betriebe:

a. Betriebe, die Speisen und Getränke als Takeaway anbieten, und Lieferdienste für Mahlzeiten;

[...]

Gleichzeitig hielt der Bundesrat fest, dass die Kantone ihre Skigebiete grundsätzlich geöffnet lassen dürfen. Einige Kantonsregierungen (darunter auch diejenige des Kantons G) liessen nicht nur die Skigebiete im Kanton offen. Sie erlaubten es auch, dass Restaurationsbetriebe in den Skigebieten ihre Terrassen geöffnet hielten und für Gäste Tische bereitstellten. Die entsprechende Regierungsverordnung im Kanton G lautete:

Regierungsverordnung des Kantons G über Restaurationsbetriebe in Skigebieten

1. Restaurationsbetrieben, die Speisen und Getränke als Takeaway in Skigebieten anbieten, wird erlaubt, auf den Terrassen im Aussenbereich Sitzgelegenheiten an Tischen anzubieten.

2. Pro Tisch dürfen maximal vier Personen sitzen und die Tische müssen einen Abstand von mindestens 1,5 Metern aufweisen.

3. Der Betrieb muss eine Person anstellen, welche die Einhaltung der Vorgaben kontrolliert, durchsetzt und die Personenströme lenkt.

Frage 1: [9 Punkte]
Die Regierung des Kantons G war der Meinung, dass ihre Regelung ***nicht*** gegen Art. 5*a* der *Covid-19-Verordnung besondere Lage* verstösst. Wie beurteilen Sie diese Frage? Stützen Sie sich dabei insbesondere auf die ***grammatikalische und die teleologische Auslegungsmethode***!

Die Auslegung erfolgt gemäss Methodenpluralismus (**1 Zusatzpunkt**) nach der grammatikalischen, der systematischen, der historischen und der teleologischen Methode, wobei sich der Fokus vorliegend gemäss Aufgabenstellung auf die grammatikalische und die teleologische Auslegung richtet.

Grammatikalisches Auslegungselement (maximal **4 Punkte**)
Ausgangspunkt der Auslegung ist der Wortlaut der Norm (grammatikalisches Element). Gemäss Art. 5*a* Abs. 2 Covid-19-Verordnung besondere Lage gilt die Schliessung nur für jene Betriebe nicht, die «Speisen und Getränke als Takeaway anbieten» oder Lieferdienste anbieten. Der Begriff «Take*away*» impliziert dabei, dass die Speisen nicht unmittelbar beim Betrieb zu konsumieren sind. (Auch «Lieferdienste» meint nur Betriebe, die Speisen an einen *anderen* Ort zum Verzehr liefern.) Die Regelung des Kantons G, die den Betrieben dagegen auf ihren Terrassen (also unmittelbar vor Ort) das Aufstellen von Tischen für die Konsumation erlaubt, geht nach grammatikalischer Auslegung also über die Ausnahmebestimmung von Art. 5*a* Abs. 2 Covid-19-Verordnung besondere Lage hinaus.

Teleologisches Auslegungselement (maximal **4 Punkte**)
Das teleologische Auslegungselement fragt nach Sinn und Zweck der auszulegenden Norm. Die Verordnung des Bundesrates dient der öffentlichen Gesundheit; gemäss Sachverhalt ging es darum, die Covid-19-Fallzahlen zu senken, um die Menschen zu schützen und die Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Es sind hierbei zwei Argumentationslinien denkbar:

(i) Die dargestellte Regelung des Kantons G könnte dazu führen, dass mehr Personen in die Skigebiete kommen – insbesondere Personen, die angesichts fehlender Verpflegungsmöglichkeiten zu Hause geblieben wären. Dies könnte zu mehr Ansteckungen führen, was dem Ziel des Bundesrates zuwiderläuft. Zu Ansteckungen könnte es insbesondere auf den Terrassen während der Konsumation kommen. Gerade dies wollte der Bundesrat mit seiner Schliessung verhindern. Diese Argumentation spricht folglich gegen die Zulässigkeit der Massnahme des Kantons G.

(ii) Die kantonale Verordnung sieht andererseits vor, dass die Gäste nur in Vierergruppen konsumieren dürfen und zwischen den Tischen ein Abstand bestehen muss. Eine Person des Betriebs hat dies auch zu kontrollieren und durchzuset-

zen. Damit ist eine geordnete Konsumation möglich. Wenn die Terrassen geschlossen werden, würden sich die Skigäste unter Umständen in noch grösseren Gruppen und in ungeordneter Weise verpflegen, was gar zu mehr Ansteckungen führen könnte.

Fazit (**1 Punkt**)

Frage 2: [3.5 Punkte]
Gehen Sie im Folgenden davon aus, die kantonale Regierungsverordnung lässt sich mit Art. 5*a* der Verordnung des Bundesrates ***nicht*** vereinbaren. Was bedeutet dies für die kantonale Norm?

Art. 49 Abs. 1 BV besagt, dass Bundesrecht entgegenstehendem kantonalem Recht vorgeht (**1 Punkt**), was auch als «derogatorische Kraft des Bundesrechts» bezeichnet wird (**0.5 Punkte**). Zum Bundesrecht gehört auch die Covid-19-Verordnung besondere Lage vom Bundesrat; zum kantonalen Recht dagegen die Regierungsverordnung des Kantons G (**1 Punkt**). Da das kantonale Recht dem Bundesrecht gemäss Fragestellung entgegensteht, darf es insoweit nicht angewendet werden (**1 Punkt**).

Zusatzpunkte:
Dasselbe ergibt sich auch aus als Folge der Kompetenzordnung gemäss Art. 3 i.V.m. 42 BV. Bei der Covid-19-Verordnung besondere Lage handelt es sich um kompetenzmässig erlassenes Recht. Art. 118 Abs. 2 lit. b BV begründet auf dem entsprechenden Gebiet eine umfassende, nachträglich derogatorische Bundeskompetenz. Wenn der Bund gestützt darauf die Frage der Restaurationsbetriebe regelt, darf der Kanton G nicht eine *unterschiedliche Regelung* zur *gleichen Frage* aufstellen.

Frage 3: [5.5 Punkte]
Der Kanton G hält an seiner Auffassung fest und will die Terrassen in den Skigebieten weiterhin nicht schliessen. Mit welchen Mitteln könnte der Bund einem solchen Konflikt mit einem Kanton begegnen? Auf welchen Verfassungsbestimmungen gründen diese Mittel?

Art. 49 Abs. 1 BV legt fest, dass in solchen Konflikten das Bundesrecht vorgeht. Der Bund hat gemäss Art. 49 Abs. 2 BV (vgl. auch Art. 186 Abs. 4 BV) auch über die Einhaltung des Bundesrechts zu wachen (**1 Punkt**). Diese Tätigkeit heisst *Bundesaufsicht* (**0.5 Punkte**).
Der Bund verfügt über verschiedene Aufsichtsmittel. Vorliegend könnte der Bund das Offenhalten der Skiterrassen in einem ersten Schritt *konkret beanstanden* (**1 Punkt**) und anschliessend *Inspektionen* zur Kontrolle durchführen (**1 Punkt**).

Da der Kanton G offenbar eine andere Rechtsauffassung hat, könnte der Bund insbesondere auch die (bundes)gerichtliche Klärung der Frage veranlassen (vgl. auch Art. 189 Abs. 2 BV) (**1 Punkt**). Alternativ/zusätzlich könnte der Bundesrat auch seine Verordnung präzisieren, um der Auffassung von G *jegliche* Grundlage zu entziehen (**1 Zusatzpunkt**).
Sollte sich der Kanton G weiterhin uneinsichtig zeigen, könnte der Bund weitere repressive Aufsichtsmittel einsetzen. Insbesondere könnte er die Skiterrassen (mit eigenem Personal) räumen lassen (*Ersatzvornahme*) (**1 Punkt**).

Aufgabe 3 — 27 Punkte

Der Sachverhalt ist frei erfunden!

Die Stadt Chur ist eine Gemeinde im Kanton Graubünden. Die Einwohnerinnen und Einwohner von Chur sind überhaupt nicht zufrieden mit dem Pandemie-Management des Kantons. Die kantonale Impfstrategie sei völlig ungenügend. Zudem hätte der Kanton in den Wintermonaten 2020/2021 unbedingt die Skigebiete schliessen müssen, um Ansteckungen und eine Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern. Es bildet sich in Chur ein Komitee, das sich vom Kanton Graubünden lossagen will. Das Komitee strebt die Gründung eines neuen Kantons, des Kantons Chur, an, um in Chur ein effektives Pandemie-Management zu gewährleisten.

In der übrigen Bevölkerung des Kantons Graubünden ist man mit der Churer Kritik an der kantonalen Pandemie-Strategie überhaupt nicht einverstanden. Graubünden habe insbesondere früh auf Massentests gesetzt, womit die Fallzahlen auch während der Wintermonate nicht explodiert seien. Unter anderem deshalb stösst auch die Idee eines neuen Kantons Chur im übrigen Graubünden auf wenig Zustimmung.

Frage 1: [9 Punkte]
Welches Verfahren wäre nach der geltenden Bundesverfassung für die Gründung des neuen Schweizer Kantons Chur einzuhalten? Wie schätzen Sie die Erfolgsaussichten dieses Unterfangens ein?

Bei diesem Unterfangen würde es sich um eine Änderung im Bestand der Kantone handeln (**0.5 Punkte**). Das Verfahren richtet sich nach Art. 53 Abs. 2 BV (**0.5 Punkte**). Erstens müsste die Bevölkerung im betroffenen Gebiet, das heisst die Bevölkerung der Gemeinde Chur, dem Unterfangen zustimmen (**1 Punkt**). Bei Gutheissung müsste die Neugründung auch eine Abstimmung auf Ebene des betroffenen Kantons (Graubünden) überstehen (**1 Punkt**). Erfolgt auch hier eine Gutheissung, braucht es drittens noch eine Mehrheit von Volk und Ständen (**1 Punkt**). Dies ergibt sich auch daraus, dass als Folge des Projekts Art. 1 BV (Aufzählung der Kantone) sowie Art. 150 Abs. 1 BV (Zusammensetzung des Ständerats) anzupassen wären (**2 Punkte**), was Volk und Stände gutheissen müssen (**1 Punkt**).
Angesichts der Tatsache, dass das Projekt im übrigen Graubünden nicht auf grosse Zustimmung stösst, wird das Projekt in der kantonalen Abstimmung wohl unterliegen (**1 Punkt**), womit die Erfolgsaussichten als gering einzustufen sind (**1 Punkt**).

Fortsetzung des Sachverhalts:

Gehen Sie im Folgenden davon aus, dass die beabsichtigte Gründung des neuen Kantons Chur ***das Verfahren aus Frage 1 tatsächlich erfolgreich durchlaufen hat***. Die Churer Bevölkerung setzt daraufhin einen Verfassungsrat ein, um einen Entwurf einer Verfassung für den neuen Kanton auszuarbeiten. Der Entwurf muss dann in einer Volksabstimmung vor der Churer Bevölkerung bestehen.
Die neue Verfassung soll ganz im Zeichen einer effektiven Pandemiebekämpfung stehen. Dazu sei es gemäss dem Verfassungsrat insbesondere notwendig, dass das Churer Parlament schnell Gesetze erlassen könne, die nicht noch ein mögliches Referendum durchlaufen müssen, bevor sie in Kraft treten. Die Mitsprache der Bevölkerung sei durch die Volkswahl des Parlaments genügend gewährleistet. Ausserdem könne die Bevölkerung den Verfassungsentwurf in der anberaumten Volksabstimmung ja ablehnen, wenn sie damit nicht einverstanden ist. Als (einziger) Weg der Verfassungsrevision sehe der Entwurf zudem vor, dass die Verfassung mit Volksmehr jederzeit wieder geändert werden könne.

Frage 2: [8 Punkte]
Wenn die Churer Bevölkerung den Verfassungsentwurf annimmt, bedarf die neue Kantonsverfassung noch der Gewährleistung des Bundes. Welche Zwecke werden mit der Gewährleistung der Kantonsverfassungen verfolgt? Wie verhält sich die Gewährleistung der Kantonsverfassungen zur Organisationsautonomie der Kantone?

Erstens stellt der Bund damit im Sinne einer Art präventiven Rechtskontrolle sicher, dass die verfassungsmässige Ordnung der Kantone dem übergeordneten Bundesrecht entspricht (vgl. Art. 51 Abs. 2 und auch Art. 49 BV) (**2 Punkte**). Teil des Bundesrechts ist auch die Forderung in Art. 51 Abs. 1 Satz 1 BV, dass sich die Kantone (wie auch der Bund) als Demokratien (mit Verfassungsreferendum) zu konstituieren haben (**1 Punkt**). Diese Forderung stellt eine Grenze der Organisationsautonomie der Kantone dar (vgl. Art. 47 Abs. 2 BV) und gewährleistet, dass sich die staatsrechtlichen Verhältnisse im Bundesstaat trotz der Vielfalt zumindest an den gleichen Grundentscheidungen orientieren (**2 Punkte**).

Zum anderen übernimmt der Bund mit der Gewährleistung auch eine «Garantenrolle» bzw. die Verpflichtung, die verfassungsmässige Ordnung der Kantone zu schützen (**1 Punkt**). Die Verletzung kantonaler verfassungsmässiger Rechte kann denn auch vor Bundesgericht geltend gemacht werden (Art. 189 Abs. 1 Bst. d BV) und der Bund muss intervenieren, wenn der Schutz der kantonalen verfassungsmässigen Ordnung dies verlangt (Art. 52 BV) (**2 Punkte**).

[*Teil 6 des Readers, S. 31 f.; Frage 30 im Fragenkatalog 3; Pierre Tschannen, Staatsrecht, S. 263.*]

Frage 3: [10 Punkte]
Beurteilen Sie anhand der Anhaltspunkte im Sachverhalt, ob der Bund die Verfassung des neuen Kantons Chur gewährleisten würde.

Der Bund gewährleistet Kantonsverfassungen, wenn sie dem Bundesrecht nicht widersprechen (Art. 51 Abs. 2 BV) (**1 Punkt**). Zum Bundesrecht gehört insbesondere auch die Vorgabe aus Art. 51 Abs. 1 BV, wonach sich die Kantone eine demokratische Verfassung zu geben haben (**1 Punkt**). Dieses Kriterium ist dann erfüllt, wenn das Parlament direkt vom Volk gewählt wird und die Staatsorganisation eine gewaltenteilige ist (**1 Punkt**). Gemäss Sachverhalt sieht die Verfassung die Volkswahl des Parlaments vor (**1 Punkt**). Hinweise, wonach die Staatsorganisation nicht gewaltenteilig sei, liegen im Sachverhalt keine vor (**0.5 Punkte**).
Art. 51 Abs. 1 Satz 2 BV sieht ausserdem vor, dass die Verfassung und Verfassungsänderungen einer Volksmehrheit bedürfen und verlangt die jederzeitige Revidierbarkeit, wenn die Mehrheit der Stimmberechtigten dies verlangt (**1 Punkt**). Gemäss Sachverhalt ist auch dies gewährleistet (**1 Punkt**). Das Bundesrecht schreibt den Kantonen dagegen gerade *nicht* vor, dass sie auch ein Gesetzesreferendum vorsehen (**1.5 Punkte**).
Auch sonst liegen im Sachverhalt keine Hinweise auf eine anderweitige Bundesrechtswidrigkeit der Churer Kantonsverfassung vor (**1 Punkt**).

Fazit: Die Voraussetzungen für eine Gewährleistung der Verfassung des neuen Kantons Chur sind mithin erfüllt (**1 Punkt**).

Aufgabe 4 — 19 Punkte

Der Sachverhalt ist frei erfunden!

Anfang 2020 eröffnet Metzger Moritz Müller in der St. Galler Altstadt einen Wurststand. Er hat leckere Bratwürste aus St. Gallen in seinem Angebot. Bereits innert kurzer Zeit hat sich die gute Qualität von Müllers Würsten herumgesprochen, sodass sein Geschäft trotz tiefen Wintertemperaturen gut läuft.

Anfang März 2020 erleidet Müller jedoch einen heftigen Rückschlag: Aufgrund der sich ausbreitenden Covid-19-Pandemie entzieht ihm die Stadtpolizei St. Gallen nach vorgängiger Anhörung die Bewilligung für seinen Wurststand. Im entsprechenden Brief teilt ihm die Stadtpolizei aber mit, er könne diesen Entscheid beim Stadtrat (Exekutive der Stadt St. Gallen) anfechten. Wenn er ein Schutzkonzept gemäss den kantonalen Richtlinien vorlegen könne, würde ihm der Stadtrat den Betrieb des Wurststands wieder erlauben. Müller reicht noch am gleichen Tag ein kurzes Schreiben beim Stadtrat ein und legt ein Schutzkonzept bei, das sich an den geltenden kantonalen Vorgaben für Schutzkonzepte orientiert.

Müller wird zwei Tage später der Eingang seines Schreibens bestätigt. Bis Anfang Mai 2020 hört er sonst aber nichts mehr vom Stadtrat.

Frage 1: [7.5 Punkte]
Gibt es eine Verfahrensgarantie in der Bundesverfassung, die der Stadtrat verletzt hat?

Im vorliegenden Verfahren *entscheidet* der Stadtrat als staatliche Behörde (und damit *verbindlich*) über die (*individuell-konkrete*) Frage, ob Müller seinen Stand in der Altstadt weiterhin betreiben darf (**1 Punkt**). Die allgemeinen Verfahrensgarantien sind damit anwendbar (**0.5 Punkte**).

Art. 29 Abs. 1 BV (**0.5 Punkte**) erwähnt ausdrücklich den Anspruch auf «Beurteilung innert angemessener Frist». Die angemessene Dauer von Verfahren kann nicht nach starren Regeln oder mit absoluten Zeitangaben bemessen werden; es ist vielmehr in jedem Einzelfall zu prüfen, ob sich die Dauer unter den konkreten Umständen als angemessen erweist (**1 Punkt**).

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts sind insbesondere die Art des Prozesses, die Komplexität der sich stellenden Sachverhalts- und Rechtsfragen, die Bedeutung der Streitsache und insb. des Zeitfaktors für die Betroffenen sowie das Verhalten der Prozessparteien zu berücksichtigen (**je 0.5 Punkte für Nennung des Kriteriums und je weitere 0.5 Punkte für Subsumtion; insgesamt 4 Punkte**).

Fazit (**0.5 Punkte**)

Fortsetzung des Sachverhalts:

Anfang Mai 2020 findet in St. Gallen eine der ersten Covid-19-Demonstrationen statt. Auch Michelle Meier will an der Demonstration teilnehmen. Sie gehörte zu den Stammkundinnen und Stammkunden von Metzger Müllers Wurststand in der Altstadt und ist sehr wütend, dass Müller seinen Stand schliessen musste. Sowieso lehnt sie die «unsinnigen» Covid-19-Massnahmen gänzlich ab und will ihre Frustration zum Ausdruck bringen. An der Demonstration sieht Meier aus der Ferne, wie sich eine Demonstrantin eine heftige Schlägerei mit einer Polizistin liefert. Letztlich kann die Demonstrantin flüchten. Tags darauf wird Meier von der Polizei informiert, dass die Polizei sie im Rahmen eines Strafverfahrens verdächtigt, sich Tags zuvor an der Demonstration in St. Gallen an einer Schlägerei beteiligt zu haben.

Meier ist schockiert angesichts dieser Nachricht. Glücklicherweise war sie während der ganzen Demonstration neben Müller, der bezeugen kann, dass sie in keine Schlägerei verwickelt war.

Frage 2: [7 Punkte]
Verleiht die Bundesverfassung Meier einen Anspruch darauf, dass Müller als Zeuge angehört wird?

Auch in diesem Verfahren sind die allgemeinen Verfahrensgarantien einschlägig (**0.5 Punkte**), da das von staatlichen Behörden geführte (Straf-)Verfahren (nur) die konkrete Schlägerei und die darin Involvierten betrifft, also einen verbindlichen, individuell-konkreten Entscheid zur Folge haben wird (**1 Punkt**).

Zu den allgemeinen Verfahrensgarantien gehört insbesondere der Anspruch auf rechtliches Gehör gemäss Art. 29 Abs. 2 BV (**1 Punkt**). Das Bundesgericht leitet daraus unter anderem den Anspruch auf Mitwirkung am Beweisverfahren ab (**1 Punkt**). Danach haben die Verfahrensparteien das Recht, aktiv an der Ermittlung des Sachverhalts mitzuwirken, weshalb sie insbesondere Beweisanträge (z.B. auf Einvernahme von entlastenden Zeugen) stellen dürfen (**1 Punkt**). Als Zwischenfazit kann damit festgehalten werden, dass Meier in diesem Verfahren zumindest den Antrag auf Einvernahme von Müller als Zeuge stellen darf (**0.5 Punkte**). Die Behörde muss Beweisanträgen Folge geben, wenn sie rechtzeitig angeboten werden, einen Beitrag zur Klärung des Sachverhalts leisten können und nicht offensichtlich untauglich sind (**1 Punkt**). Vorliegend ist Müller anzuhören (**0.5 Punkte, Fazit**), weil er als Meiers (behaupteter) Begleiter tatsächlich Auskunft über Meiers Verhalten während der Demonstration geben und damit zur Klärung des Sachverhalts beitragen könnte (**0.5 Punkte, Begründung**).

Frage 3: [4.5 Punkte]
Gehen Sie davon aus, dass das St. Galler Kreisgericht über die Verurteilung von Michelle Meier zu entscheiden hat. An diesem Gericht ist unter anderem auch Roger Hart als gewählter Richter tätig. Hart ist mit der Polizistin, die in die Schlägerei an der Demonstration involviert war, in einer langjährigen Liebesbeziehung. Gibt es eine Verfassungsbestimmung, aufgrund welcher Hart am Entscheid betreffend Meier ***nicht*** mitwirken darf?

Da es sich gemäss Fragestellung um ein gerichtliches Verfahren handelt, ist Art. 30 Abs. 1 BV einschlägig, der die richterliche Unabhängigkeit garantiert (**0.5 Punkte**). Die richterliche Unabhängigkeit verlangt, dass ein Richter über den Fall entscheidet, der vom Staat unabhängig ist (**0.5 Punkte**) und der nicht durch sachfremde Umstände zugunsten oder zulasten einer Partei entscheidet – also unparteiisch/unbefangen ist (**0.5 Punkte**). Im Übrigen verlangt auch Art. 29 Abs. 1 BV, dass am Entscheid nur unbefangene und unparteiliche Richterinnen und Richter mitwirken (**1 Zusatzpunkt**). Bereits der Anschein der Befangenheit soll ausgeschlossen werden (**0.5 Punkte**). Allerdings muss die Befürchtung der Befangenheit eine gewisse Intensität erreichen sowie objektivierbar sein, also nicht rein subjektiv bestehen (**0.5 Punkte**).
Subsumtion: 1.5 Punkte
Fazit: 0.5 Punkte

Universität St.Gallen

Prüfungsbooklet Assessment

Rechtswissenschaft I B

Teil Schmid

Hinweise:

- **Die alten Prüfungen dienen als Lernhilfe.**
- **Die Musterlösungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.**
- **Die zitierten Stellen des Lehrbuchs oder die angegebenen Folien beziehen sich auf die zum Prüfungszeitpunkt aktuelle Auflage bzw. aktuelle Vorlesungsstruktur.**

Universität St.Gallen

Prüfung Assessmentjahr – Frühjahrssemester 2021

Name: _____ **Vorname:** _____

Muttersprache(n): Matrikel-Nr.:

Prüfungsfach: **Rechtswissenschaft I B (schriftliche Prüfung)**
2,170

Prüfungsteil: **Prof. Dr. Stefan G. Schmid (90 Minuten)**

Verantwortlich: **Prof. Dr. Stefan G. Schmid**

Bemerkungen:

Dieser Prüfungsteil umfasst 4 Aufgaben auf 15 Seiten (inkl. diesem Deckblatt). Die Punkte verteilen sich folgendermassen auf die einzelnen Aufgaben:

Aufgabe 1	10 Punkte
Aufgabe 2	40 Punkte
Aufgabe 3	10 Punkte
Aufgabe 4	30 Punkte
Total	**90 Punkte**

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie bei der Bearbeitung dieser Prüfung folgende Hinweise:

1. Verwenden Sie für die Lösungen den freigehaltenen Platz unterhalb der Fragen. Sollte der zur Verfügung stehende Platz nicht genügen, bitten Sie die Prüfungsaufsicht um ein Zusatzblatt. Verwenden Sie für jede Aufgabe ein neues Zusatzblatt und kennzeichnen Sie genau, um welche Aufgabe in welchem Teil der Prüfung es sich handelt. Schreiben Sie auf jedes Zusatzblatt Ihren Namen sowie Ihre Matrikelnummer und nummerieren Sie die Blätter.
2. **Begründen Sie alle Antworten und nennen Sie, wo vorhanden, die entsprechenden rechtlichen Bestimmungen.**
3. Bitte formulieren Sie ganze Sätze und versuchen Sie, Ihre Ausführungen strukturiert und übersichtlich aufzubauen. Achten Sie auf eine leserliche Handschrift.

Aufgabe 1: «Kontrollschildinitiative» (10 Punkte)

Die Bundeskanzlei teilte am 17. November 2020 mit, dass für die eidgenössische Volksinitiative «Integration des Landeskennzeichens in das Kontrollschild (Kontrollschildinitiative)» innert Sammelfrist nicht genügend Unterschriften gesammelt wurden, weshalb die Volksinitiative bereits im Sammelstadium gescheitert sei.

Die Volksinitiative hatte folgenden Wortlaut:

> *Das Design der Kontrollschilder für Motorfahrzeuge und Anhänger soll so angepasst werden, dass keine Notwendigkeit mehr besteht, einen CH-Aufkleber anzubringen, wenn man ins Ausland fährt. Das bedeutet mindestens, dass unser Landeskennzeichen CH auf dem Kontrollschild steht. Dem Gesetzgeber wird freigestellt, ob er zugleich noch weitere notwendige Anpassungen vornehmen möchte.*
>
> *Das neue Design der Kontrollschilder soll spätestens zwei Jahre nach der Annahme der ausformulierten Verfassungsbestimmung durch Volk und Stände eingeführt werden.*

Frage 1)
Prüfen Sie, ob die «Kontrollschildinitiative» die Gültigkeitsvoraussetzung der Einheit der Form erfüllt hätte. (6 Punkte)

Die Einheit der Form ist in Art. 139 Abs. 3 BV, Art. 194 Abs. 2 BV und in Art. 75 Abs. 1 BPR verankert. Die Gültigkeitsvoraussetzung verlangt, dass die Volksinitiative entweder vollständig als ausgearbeiteter Entwurf oder vollständig als allgemeine Anregung vorliegen muss.

- *Ein ausgearbeiteter Entwurf wird wortwörtlich in die Verfassung aufgenommen, wenn die Volksinitiative in der Abstimmung angenommen wird.*
- *Eine allgemeine Anregung hingegen ist so formuliert, dass der Text nicht direkt in die Verfassung übernommen werden soll. Sie stellt vielmehr eine verpflichtende Anregung an das Parlament dar, einen oder mehrere Verfassungsartikel im Sinne der Initiative auszuarbeiten. Sie enthält eine Leitidee und gibt dem Parlament Spielraum bei der Ausarbeitung der Formulierung.*

In casu: *Im vorliegenden Fall handelt es sich ausschliesslich um eine allgemeine Anregung, was insbesondere durch die Bezeichnung «soll angepasst werden» bzw. «soll spätestens (…) eingeführt werden», ersichtlich wird. Der Text der Volksinitiative kann nicht wörtlich in die Verfassung aufgenommen werden, vielmehr handelt es sich dabei um eine verpflichtende Anregung an das Parlament.*

Fazit*: Die Einheit der Form ist gewahrt.*

GIOVANNI BIAGGINI/THOMAS GÄCHTER/REGINA KIENER (Hrsg.), Staatsrecht, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2015, § 23 N. 70, N. 96 ff.

Frage 2)

Leon, der im September das Assessmentjahr an der HSG beginnt und sich sehr für das Staatsrecht interessiert, ist über das Scheitern der «Kontrollschildinitiative» im Sammelstadium erleichtert. Seiner Meinung nach gehört die Regelung des Designs der Kontrollschilder nicht in die Bundesverfassung, sondern allenfalls in eine Verordnung. Erklären Sie Leon, weshalb auch eine eher «unwichtige» Materie wie das Design der Kontrollschilder Gegenstand einer eidgenössischen Volksinitiative sein kann! (4 Punkte)

Auf Bundesebene muss jede Volksinitiative auf die Teilrevision oder gar die Totalrevision der Bundesverfassung abzielen (Art. 138 und 139 BV). Es ist jedoch kein verfassungswürdiger Inhalt gefordert, d.h. auch Gegenstände der Gesetzes- oder der Verordnungsstufe oder gar Einzelakte können Materie einer eidgenössischen Volksinitiative sein. Die Bundesverfassung kennt somit keinen ***rechtlich verbindlichen materiellen Verfassungsbegriff****. Anerkannte Voraussetzungen der Verfassungsrevision sind einzig die Einheit der Form, die Einheit der Materie, die Beachtung zwingender Bestimmungen des Völkerrechts sowie die faktische Durchführbarkeit.*

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 23 N. 69 ff.; § 24 N. 58 ff.
Vorlesung 2/I Folie 23

Aufgabe 2: Parlamentarische Initiative Suter (40 Punkte)

Lesen Sie den folgenden Auszug aus einem Zeitungsartikel von Mitte März 2021 und beantworten Sie die nachfolgenden Fragen.

SVP-Nationalräte Wobmann und Imark unterstützen SP-Initiative für mehr Volksrechte

Es hat Seltenheitswert, wenn eine SP-Nationalrätin für eine Initiative Unterstützung aus der SVP bekommt. Die beiden Solothurner Christian Imark und Walter Wobmann unterschrieben einen Vorstoss von Gabriela Suter (SP, Aargau). Es geht um Volksrechte und Anliegen wie das Burkaverbot.

«Nun haben wir neben einem Bauverbot für Minarette neu auch Kleidervorschriften in der Verfassung», ärgert sich Gabriela Suter immer noch und meint damit das Burkaverbot. «Damit dies nicht weiter ausufert», wie die Aargauer SP-Nationalrätin sagt, reicht sie eine parlamentarische Initiative ein, die Volksinitiativen auch auf Gesetzesebene ermöglichen soll.

[…]

Nationalrat Andreas Glarner (SVP, Aargau) bestätigt auf Anfrage, er habe «Sympathien» für Suters Vorschlag, aber nach Rücksprache mit der SVP-Fraktion habe er sich entschieden, die parlamentarische Initiative nicht zu unterstützen. Aus inhaltlichen Gründen: Ein Gesetz, das über eine Volksinitiative nach aufwändigem Unterschriftensammeln durchgesetzt würde, könnte das Parlament problemlos – zum Beispiel mit einer Motion – wieder abschaffen, so Glarner. Darum bringe eine solche Gesetzesinitiative nicht viel.

[…]

Schon 1987, 2004, 2009 und zuletzt 2014 gab es vergleichbare Vorstösse. Jedes Mal ohne Erfolg. Eines der Hauptargumente der Gegner formulierte damals CVP-Präsident Gerhard Pfister: Die Gesetzesinitiative würde in der Umsetzung kompliziert, das Parlament hätte – anders als bei der heutigen Verfassungsinitiative – kaum noch Spielraum. Zudem biete eine Volksinitiative auf Gesetzesstufe die Möglichkeit, das Ständemehr zu umgehen, was die kleineren Kantone schwächen würde.

[…]

Als nächstes wird Suters parlamentarische Initiative für mehr Volksrechte in der zuständigen Staatspolitischen Kommission des Nationalrats behandelt. Pikant: Präsidiert wird diese von SVP-Mann Andreas Glarner.

Frage 1)
Nationalrätin Suter möchte eine parlamentarische Initiative einreichen, die Volksinitiativen auch auf Gesetzesebene ermöglichen soll.

a) Was versteht man ganz allgemein unter einer parlamentarischen Initiative? (3 Punkte)

Eine parlamentarische Initiative (Art. 160 Abs. 1 BV; Art. 107 ff. ParlG) ist ein parlamentarisches Handlungsinstrument. Die parlamentarische Initiative ist ein Vorschlag, dass eine Kommission einen Entwurf zu einem Erlass der Bundesversammlung ausarbeitet. Die parlamentarische Initiative erlaubt es dem Parlament, in eigener Regie und ohne Mitwirkung von Bundesrat und Bundesverwaltung einen Erlassentwurf auszuarbeiten.

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 18 N. 82
Vorlesung 2/IV Folie 20

b) Im Zeitungsartikel ist ferner von der Motion die Rede. Was versteht man ganz allgemein unter einer Motion? (3 Punkte)

Die Motion zählt zu den parlamentarischen Vorstössen gemäss Art. 118 ParlG. Eine Motion (Art. 171 BV; Art. 120 ff. ParlG) ist ein verbindlicher Auftrag an den Bundesrat, einen Entwurf zu einem Erlass der Bundesversammlung vorzulegen oder eine Massnahme zu treffen. Sie darf auch auf den «Zuständigkeitsbereich des Bundesrates einwirken» (Art. 171 Satz 2 BV). Unbesehen der Einwirkungsmöglichkeit muss die Entscheidungskompetenz jedoch beim Bundesrat verbleiben.

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 18 N. 84
Vorlesung 2/IV Folie 20

Frage 2)
Erklären Sie, was unter dem Volksrecht der Gesetzesinitiative zu verstehen ist und äussern Sie sich zu deren Verbreitung in den Kantonen. (2 Punkte)

Eine Gesetzesinitiative ist eine Initiative, die auf die Revision eines bestehenden oder die Einführung eines neuen Gesetzes abzielt. Sämtliche Kantone kennen die Gesetzesinitiative.

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 24 N. 58 f.

Frage 3)
Gemäss CVP/Mitte-Präsident Pfister böte die Einführung einer solchen Gesetzesinitiative die Möglichkeit, das Ständemehr «zu umgehen», was die kleineren Kantone schwächen würde.

a) Weshalb würden durch die Möglichkeit, das Ständemehr «zu umgehen», besonders die kleineren Kantone geschwächt? (4 Punkte)

Grund hierfür ist, dass die Kantone grundsätzlich unabhängig von ihrer Bevölkerungszahl über eine Standesstimme verfügen. Dies hat zur Folge, dass etwa dem bevölkerungsschwachen Kanton Uri das gleiche Gewicht zukommt wie dem bevölkerungsstarken Kanton Zürich. Lediglich die Kantone Obwalden, Nidwalden, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden, früher als Halbkantone bezeichnet, verfügen nur über eine halbe Standesstimme (Art. 142 Abs. 4 BV). Das gleiche Gewicht jeder Standesstimme lässt sich mit dem Grundsatz der Gleichheit der Kantone erklären.

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 23 N. 65
Vorlesung 2/I Folie 39

b) Wer entscheidet im jeweiligen Kanton, ob dieser eine Volksinitiative auf Verfassungsrevision annimmt oder ablehnt, also ob dessen Standesstimme als zustimmend oder verwerfend gezählt wird?
(2 Punkte)

Das Ergebnis der Volksabstimmung im Kanton gilt als dessen Standesstimme (Art. 142 Abs. 3 BV).

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 23 N. 65

Frage 4)
Im Zeitungsartikel wird, wie bereits erwähnt, CVP/Mitte-Präsident Pfister zitiert. Darf eine Parteipräsidentin oder ein Parteipräsident der Bundesversammlung angehören? (4 Punkte).

Unvereinbarkeiten sind in der Bundesverfassung in Art. 144 BV geregelt. Als Ausdruck der personellen Gewaltenteilung können die Mitglieder von Nationalrat und Ständerat nicht gleichzeitig der anderen Parlamentskammer, dem Bundesrat oder dem Bundesgericht angehören (Art. 144 Abs. 1 BV). Gemäss Abs. 3 kann das Gesetz weitere Unvereinbarkeiten vorsehen.

Gesetzliche Unvereinbarkeiten sieht das Parlamentsgesetz in Art. 14 Bst. a–f vor. Das Amt des Parteipräsidenten wird jedoch nicht erwähnt. Ferner dürfen als Ausdruck des Milizprinzips Mitglieder der Bundesversammlung daneben insbesondere eine Erwerbstätigkeit ausüben. Eine Tätigkeit als Parteipräsidentin oder Parteipräsident, ob bezahlt (z.B. bei der FDP) oder unbezahlt (z.B. bei der SVP), stellt demnach keine Unvereinbarkeit dar.

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 18 N. 30 ff.

Frage 5)
Gemäss Zeitungsartikel hat sich Nationalrat Glarner nach Rücksprache mit der SVP-Fraktion entschieden, die parlamentarische Initiative nicht zu unterstützen.

a) Inwiefern äussert sich die Bundesverfassung zu den Fraktionen? (3 Punkte)

Die Bundesverfassung sieht vor, dass die Mitglieder der Bundesversammlung Fraktionen bilden können (Art. 154 BV). Zudem verfügen Fraktionen gemäss Art. 160 BV über ein Initiativ- bzw. Antragsrecht.

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 18 N. 75

b) Wie setzt sich eine Fraktion zusammen? Ab wie vielen Mitgliedern kann eine Fraktion gebildet werden? (4 Punkte)

Die Fraktionen setzen sich aus Mitgliedern beider Räte mit gleicher Parteizugehörigkeit zusammen; eine ähnliche politische Ausrichtung vorausgesetzt, können auch Parteilose und Angehörige unterschiedlicher Parteien eine Fraktion bilden (Art. 61 Abs. 1 und 2 ParlG). Einer Fraktion müssen mindestens fünf Mitglieder eines Rates angehören (Art. 61 Abs. 3 ParlG).

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 18 N. 75

c) Welches sind zahlenmässig die beiden grössten Fraktionen der 51. Legislaturperiode der Bundesversammlung (2019–2023)? (2 Punkte)

Die grösste Fraktion stellt diejenige der Schweizerischen Volkspartei (SVP-Fraktion) dar, gefolgt von der Sozialdemokratischen Fraktion (SP-Fraktion).

Vorlesung 2/IV Folien 18 und 41

Frage 6)

Gemäss Zeitungsartikel wird Nationalrätin Suters parlamentarische Initiative für mehr Volksrechte nun in der zuständigen Staatspolitischen Kommission des Nationalrats behandelt.

a) Was sind Kommissionen? Warum ist es für Parlamentsmitglieder wichtig, in Kommissionen Einsitz nehmen zu können? (4 Punkte)

Die Räte setzen zur Vorbereitung und Erleichterung der Ratsarbeit parlamentarische Kommissionen ein (Art. 153 BV). Kommissionen sind Arbeitsausschüsse, deren Aufgabe wesentlich darin liegt, die Ratsgeschäfte zuhanden des Plenums vorzuberaten, dem Rat Bericht zu erstatten und Anträge zu stellen (Art. 44 ParlG).
Die Rechte der Kommissionen ergeben sich aus Verfassung und Gesetz (z.B. Art. 45 ParlG). Namentlich können die Kommissionen zur Erfüllung ihrer Aufgaben parlamentarische Initiativen, Vorstösse und Anträge einreichen sowie Berichte erstellen (Art. 45 Abs. 1 Bst. a ParlG). Die Hauptarbeit wird somit in den Kommissionen geleistet, weshalb es auch wichtig ist, in Kommissionen Einsitz nehmen zu können.

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 18 N. 68 ff.
Vorlesung 2/IV Folie 18

b) Äussern Sie sich zum Wahlorgan und zur Zusammensetzung der ständigen Kommissionen! (3 Punkte)

Wahlorgan ist das jeweilige Ratsbüro (Art. 43 Abs. 1 ParlG). Die Sitzzuteilung erfolgt proportional zur Stärke der Fraktionen im jeweiligen Rat; soweit möglich werden die Amtssprachen und Landesgegenden angemessen berücksichtigt (Art. 43 Abs. 3 ParlG).

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 18 N. 72

c) Der Journalist, der den vorn wiedergegebenen Zeitungsartikel verfasst hat, interessiert sich sehr für dieses Thema und möchte möglichst viele Informationen aus den Kommissionssitzungen erhalten; am liebsten würde er den Sitzungen der Staatspolitischen Kommission als Gast beiwohnen. Darf er das? Äussern Sie sich zur Öffentlichkeit von Kommissionssitzungen! (4 Punkte)

Anders als die Sitzungen der Bundesversammlung (Art. 158 BV) sind die Kommissionssitzungen nicht öffentlich (Art. 47 Abs. 1 ParlG), um den notwendigen Freiraum für offene Diskussionen zu sichern und die Möglichkeit von Kompromissen zu wahren. Die Kommissionen sind aber verpflichtet, die Öffentlichkeit über das Ergebnis ihrer Beratungen zu informieren (Art. 48 ParlG).

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 18 N. 74

Frage 7)

Nehmen Sie nun an, dass die parlamentarische Initiative von Nationalrätin Suter schliesslich erfolgreich sein wird und die Bundesversammlung eine entsprechende Verfassungsänderung beschliesst. Könnte dagegen das fakultative Referendum ergriffen werden? (2 Punkte)

Nein, eine Verfassungsänderung untersteht dem obligatorischen Referendum von Volk und Ständen (Art. 140 Abs. 1 Bst. a; Art. 195 BV).

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 23 N. 86

Aufgabe 3: Covid-19-Gesetz (10 Punkte)

Am 13. Juni 2021 fand die Volksabstimmung über das dringliche «Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz)» statt. Die Abstimmung war auch Thema in der politischen Diskussionssendung «Arena» des Schweizer Fernsehens. Leider stimmten aber nicht alle Aussagen der Politikerinnen und Politiker. Nehmen Sie zu jeder Aussage Stellung und legen Sie dar, inwiefern diese nach geltendem Recht zutrifft oder nicht zutrifft.

Aussage 1)
Für die Dringlicherklärung eines Bundesgesetzes durch das Parlament ist eine qualifizierte Mehrheit erforderlich. (2 Punkte)

Trifft zu. Die Annahme der Dringlichkeitsklausel erfordert eine qualifizierte Mehrheit: Die Mehrheit der Mitglieder jedes Rates – nicht nur die Mehrheit der Stimmenden – muss ihr zustimmen (Art. 165 Abs. 1; 159 Abs. 3 Bst. a BV).

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 23 N. 63
Vorlesung 2/VI Folie 17

Aussage 2)
Die Bundesverfassung äussert sich zur genauen Dauer der Befristung dringlicher Bundesgesetze. (2 Punkte)

Trifft nicht zu. Für die Dauer der Befristung lassen sich dem Verfassungstext keine Angaben entnehmen; die Bundverfassung hält lediglich in allgemeiner Weise fest, dass dringliche Bundesgesetze zu befristen sind (Art. 165 Abs. 1 Satz 2 BV). Im Hinblick darauf, dass dringliche Bundesgesetze vor allem dann erforderlich sind, wenn rasch eine Regelung geschaffen werden soll, darf die Dauer der Befristung dem dringlichen Bundesgesetz nicht den Charakter einer Dauerlösung verleihen. Die Befristung sollte deshalb wenige Jahre nicht überschreiten.

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 23 N. 52

Aussage 3)
Beim Referendum über das Covid-19-Gesetz handelte es sich um ein sogenanntes abrogatives Referendum. (2 Punkte)

Trifft zu. Es handelt sich um ein nachträgliches Referendum. Das Referendum kann in einem solchen Fall bei Ablehnung des Gesetzes nur eine abrogative, d.h. eine auflösende/aufhebende Wirkung haben.

Vorlesung 2/VI Folie 17

Aussage 4)
Es gibt dringliche Bundesgesetze, die den Volksrechten gänzlich entzogen sind, bei denen eine Volksabstimmung also ausgeschlossen ist. (2 Punkte)

Trifft zu. Dringliche Bundesgesetze, deren Geltungsdauer auf weniger als ein Jahr befristet ist, unterstehen weder einem fakultativen noch einem obligatorischen Referendum (Art. 140 Abs. 1 Bst. c BV e contrario und Art. 141 Abs. 1 Bst. b BV e contrario).

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 23 N. 58

Aussage 5)
Dringliche Bundesgesetze können mit Beschwerde direkt beim Bundesgericht angefochten werden. (2 Punkte)
Hinweis: Auf Art. 190 BV ist nicht einzugehen!

Trifft nicht zu. Eine abstrakte Normenkontrolle auf dem Beschwerdeweg ist bei Bundesgesetzen ausgeschlossen, da Akte der Bundesversammlung beim Bundesgericht nicht angefochten werden können (189 Abs. 4 BV) bzw. nur kantonale Erlasse als Anfechtungsobjekte zulässig sind (Art. 82 Bst. b BGG).

Vorlesung 2/V Folie 35

Aufgabe 4: Wohnsitzpflicht im Kanton X (30 Punkte)

Im Amtsblatt des Kantons X vom 4. April 2017 publizierte die Sicherheitsdirektion des Kantons X eine Stellenanzeige für «eine/n Chefin/Chef Bereitschafts- und Verkehrspolizei (100 %)». Als Anforderungen für diese Stelle wurde unter anderem die Bereitschaft zu unregelmässigen Arbeitszeiten und Wohnsitznahme im Kanton X verlangt. Auf diese Anzeige gingen 14 Bewerbungen ein, 7 wurden näher geprüft. Schliesslich wurde der 1972 geborene A ausgewählt, der in der Folge die Stelle auf den 1. Oktober 2017 antrat und seinen Wohnsitz vom Kanton Y in den Kanton X verlegte.
Im September 2019 informierte A seinen Arbeitgeber über seine Absicht, seinen Wohnsitz per Februar 2020 vom Kanton X wieder zurück in den Kanton Y zu verlegen. Der Arbeitsweg würde sich für A von 10 auf knapp 40 Autofahrminuten erhöhen. Nach Gewährung des rechtlichen Gehörs ordnete die Sicherheitsdirektion des Kantons X mit Verfügung vom 6. Januar 2020 gestützt auf Art. 51 des kantonalen Polizeigesetzes für A die Pflicht zur Beibehaltung eines Wohnsitzes innerhalb des Kantons X an.
Die von A hiegegen erhobene Beschwerde wies das Kantonsgericht des Kantons X mit Entscheid vom 21. September 2020 ab. Mit Beschwerde an das Bundesgericht beantragt A nun, es seien die Verfügung und der kantonale Gerichtsentscheid ersatzlos aufzuheben.

Art. 51 des kantonalen Polizeigesetzes des Kantons X, das vom hierfür zuständigen Kantonsparlament erlassen wurde, lautet wie folgt:

> Art. 51 **Wohnsitz**
> Sofern ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht, kann die Anstellungsbehörde den Angehörigen des Polizeikorps einen bestimmten Wohnsitz vorschreiben.

Nehmen Sie nun an, Sie absolvieren ein Praktikum beim Bundesgericht. Eine Bundesrichterin gibt Ihnen folgenden Auftrag:

- Prüfen Sie anhand der Prüfkriterien, ob ein Grundrechtsfall vorliegt und ob die Voraussetzungen für die zulässige Einschränkung eines Freiheitsrechts erfüllt sind.
- Gehen Sie bei der Prüfung der Grundrechtsrelevanz auf **alle Freiheitsrechte der Bundesverfassung** ein**,** die im vorliegenden Fall berührt/tangiert sein könnten. Konzentrieren Sie sich bei der nachfolgenden Prüfung der Zulässigkeit der Einschränkung aber auf das **hauptsächlich betroffene Freiheitsrecht**.
- Prüfen Sie alle Kriterien, auch wenn Sie glauben, den Entscheid schon früher treffen zu können.
- Prozessuale Fragen können Sie weglassen.

Präzisierender Hinweis (zu Beginn der Prüfung ausgeteilt): A besitzt das Schweizer Bürgerrecht.

Prüfkriterien 1: Prüfung der Grundrechtsrelevanz (Gewichtung 1/3)

a) Rechtsgrundlagen der Freiheitsrechte

Im vorliegenden Fall könnten die persönliche Freiheit (Art. 10 Abs. 2 BV) und die Niederlassungsfreiheit (Art. 24 BV) berührt sein.

b) Sachlicher Schutzbereich (Schutzobjekt)

Persönliche Freiheit:

Art. 10 Abs. 2 BV stellt die verfassungsrechtliche Grundgarantie zum Schutz der Persönlichkeit dar und verbrieft neben dem Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit sowie der Bewegungsfreiheit all jene Freiheiten, die elementare Erscheinungen der Persönlichkeitsentfaltung darstellen. Das Recht auf persönliche Freiheit ist somit eine umfassende Garantie, die alle elementaren Freiheiten einschliesst, die für die Persönlichkeitsentfaltung unverzichtbar sind.

In casu: *A möchte seinen Wohnsitz in den Kanton Y verlegen. Die freie Wahl des Wohnsitzkantones stellt eine elementare Erscheinung der Persönlichkeitsentfaltung dar.*

Fazit: *Der sachliche Schutzbereich der persönlichen Freiheit ist berührt.*

Niederlassungsfreiheit:

Gemäss Art. 24 Abs. 1 BV haben Schweizerinnen und Schweizer das Recht, sich an jedem Ort des Landes niederzulassen. Geschützt sind die Wohnsitznahme, aber auch der bloss vorübergehende Aufenthalt, sofern er von einer gewissen Dauer ist. Mit eingeschlossen ist das Recht, den Wohn- bzw. Aufenthaltsort jederzeit zu verlassen. Ferner darf die Verlegung des einmal gewählten Wohnsitzes oder Aufenthalts in einen anderen Kanton, eine andere Gemeinde oder ins Ausland grundsätzlich nicht verhindert oder erschwert werden.

In casu: *A wird zur Beibehaltung eines Wohnsitzes im Kanton X verpflichtet.*

Fazit: *Der sachliche Schutzbereich der Niederlassungsfreiheit ist berührt.*

c) Persönlicher Schutzbereich (Grundrechtsträgerschaft)

Träger der persönlichen Freiheit sind alle natürlichen, nicht aber juristische Personen. Träger der Niederlassungsfreiheit sind alle natürlichen Personen, die im Besitz des Schweizer Bürgerrechts sind.

In casu*: A ist eine natürliche Person, die das Schweizer Bürgerrecht besitzt.*

Fazit: *A ist Träger der persönlichen Freiheit sowie der Niederlassungsfreiheit.*

d) Adressat

Adressat der beiden Freiheitsrechte ist der Staat bzw. sind die staatlichen Behörden auf allen Ebenen der staatlichen Tätigkeit (Bund, Kantone, Gemeinden).

In casu: *Bei der Sicherheitsdirektion des Kantons X handelt es sich um eine staatliche Behörde auf Ebene Kanton.*

Fazit: *Die Sicherheitsdirektion des Kantons X ist Adressat der Freiheitsrechte.*

e) Zwischenergebnis der Vorprüfung

Es liegt ein Grundrechtsfall vor.

Abwägung: Die Niederlassungsfreiheit ist i.c. das spezifischere Grundrecht der beiden, weshalb nachfolgend nur noch die Niederlassungsfreiheit weiter geprüft wird.

Prüfkriterien 2: Prüfung der Zulässigkeit der Einschränkung (Art. 36 BV) (Gewichtung 2/3)

a) Gesetzliche Grundlage

Art. 36 Abs. 1 BV

Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Eine Ausnahme bildet die polizeiliche Generalklausel (Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr).

Erfordernis des Rechtssatzes:

- *Generell-abstrakte Norm: Die Freiheitsbeschränkung muss grundsätzlich in einem Rechtssatz, d.h. in einer generell-abstrakten Norm, vorgesehen sein (Art. 22 Abs. 4 ParlG). Generell ist eine Norm, wenn sie sich an eine unbestimmte Zahl von Adressaten richtet, sich also auf einen unbestimmten Adressatenkreis bezieht; abstrakt ist eine Norm, wenn sie eine unbestimmte Vielzahl von Fällen regelt.*
- *Genügende Bestimmtheit: Ein Rechtssatz muss so präzise formuliert sein, dass die Bürgerinnen und Bürger ihr Verhalten danach richten und die Folgen eines bestimmten Verhaltens mit einem entsprechenden Grad an Gewissheit erkennen können. Als Beamter steht A in einem Sonderstatusverhältnis zum Staat, weshalb die Anforderungen an die Bestimmtheit praxisgemäss gelockert sind. Die Bestimmtheit muss aber gleichwohl ausreichen, um eine rechtsgleiche und willkürfreie Behandlung der Personen im besonderen Rechtsverhältnis zu gewährleisten.*

In casu: *Gemäss Art. 51 des kantonalen Polizeigesetzes kann die Anstellungsbehörde den Angehörigen des Polizeikorps einen bestimmten Wohnsitz vorschreiben. Es handelt sich um eine generell-abstrakte Norm. Art. 51 des kantonalen Polizeigesetzes ist so präzise formuliert, dass jede Bürgerin und jeder Bürger ihr/sein Verhalten danach richten kann. Aus Art. 51 ergibt sich ohne weiteres, dass Angehörige der Polizei einer Wohnsitzpflicht unterliegen können.*

Zwischenfazit Erfordernis des Rechtssatzes: *Es liegt ein Rechtsatz vor.*

Erfordernis der Gesetzesform

Schwerwiegende Grundrechtseinschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein, d.h. in einem Gesetz im formellen Sinn (Art. 36 Abs. 1 Satz 2 BV). Nicht schwerwiegende Grundrechtseinschränkungen können auch in Erlassen niedrigerer Stufe vorgesehen sein, insbesondere in einer Verordnung.

In casu: *Das kantonale Polizeigesetz wurde vom zuständigen Organ des Kantons, dem Kantonsparlament, erlassen. Das kantonale Polizeigesetz stellt eine formell-gesetzliche Grundlage dar, weshalb insoweit die Schwere des Grundrechtseingriffs unerheblich ist.*

Zwischenfazit Erfordernis der Gesetzesform: *Das Erfordernis der Gesetzesform ist erfüllt.*

Gesamtfazit gesetzliche Grundlage:

Es liegt eine genügende gesetzliche Grundlage vor.

b) Rechtfertigende Eingriffsinteressen

Art. 36 Abs. 2 BV

Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.

Im öffentlichen Interesse liegt alles, was der Staat zum Gemeinwohl vorkehren muss, um eine ihm obliegende Aufgabe zu erfüllen. Als hinreichende öffentliche Interessen gelten z.B. die Polizeigüter (Ruhe und Ordnung, öffentliche Sicherheit, öffentliche Gesundheit, öffentliche Sittlichkeit, Treu und Glauben

im Geschäftsverkehr). Das Eingriffsinteresse des Schutzes von Grundrechten Dritter macht deutlich, dass die Grundrechtsansprüche verschiedener Grundrechtsträger miteinander kollidieren können.
Die Niederlassungsfreiheit kann eingeschränkt werden, wenn zwingende Gründe des Dienstes oder das Erfordernis besonderer Beziehungen zur Bevölkerung dies gebieten. Ferner gilt es zu erwähnen, dass von Staatsangestellten in höherer Stellung eine grössere Disponibilität gegenüber ihrem Arbeitgeber verlangt wird; namentlich spielt die Verbundenheit mit dem betreffenden Gemeinwesen eine Rolle.
In casu: *Die Aufgabe der kantonalen Polizei liegt im Schutz der Polizeigüter. Als Chef der Bereitschafts- und Verkehrspolizei ist A ein hoher Polizeioffizier mit Leitungsfunktion. In einer solch wichtigen Stellung ist die enge Verbundenheit mit dem Kanton zentral, zumal die Polizeiarbeit auch vom Vertrauen der Bevölkerung lebt. Weiter gilt es anzumerken, dass es zum Schutze der Polizeigüter wichtig ist, dass der Chef der Bereitschafts- und Verkehrspolizei im Notfall innert Kürze am Arbeitsort erscheinen kann, um Einsätze zu planen, zu koordinieren usw. Ein Arbeitsweg von 40 Minuten kann als zu lange angesehen werden.*
Fazit: *Es liegen öffentliche Interessen vor.*

c) Verhältnismässigkeit

Art. 36 Abs. 3 BV

Eignung:
Die Massnahme muss geeignet sein, den angestrebten Zweck zu erreichen.
In casu*: Die angeordnete Wohnsitzpflicht ist einerseits geeignet, einen kurzen Arbeitsweg sicherzustellen, andererseits die Verbundenheit zum Arbeitskanton aufrechtzuerhalten bzw. zu fördern.*
Fazit: *Die Eignung kann bejaht werden.*

Erforderlichkeit*:*
Die Massnahme muss den geringst möglichen Eingriff darstellen; es darf keine gleichermassen geeignete, mildere Massnahme geben, die zum gleichen Ziel führen würde. Die Wohnsitzpflicht muss somit dienstlich notwendig sein.
In casu*: Es ist kein milderes Mittel als die Anordnung der Wohnsitzpflicht ersichtlich, durch welches eine ähnlich hohe Verbundenheit mit dem Arbeitskanton aufrechterhalten bzw. ein derart kurzer Arbeitsweg sichergestellt werden könnte.*
Fazit: *Die Erforderlichkeit ist gegeben.*

Anmerkung: Die gegenteilige Ansicht wird, sofern überzeugend begründet, ebenfalls mit voller Punktzahl bewertet.

Zumutbarkeit:
Die Massnahme darf zu keinem Missverhältnis zwischen Eingriffszweck und Eingriffswirkung führen (angemessenes Zweck-Mittel-Verhältnis). Das öffentliche Interesse an der Einschränkung des Grundrechts muss das private Interesse an der ungehinderten Ausübung des Grundrechts überwiegen.

In casu (inkl. Abwägung):
Öffentliches Interesse an der Einschränkung: Verweis auf oben.
*Privates Interesse****:*** *Interesse von A seinen Wohnsitz frei zu wählen, und sich im Kanton Y niederzulassen. Aus dem Sachverhalt ergeben sich keine Anhaltspunkte, weshalb für A die Beibehaltung eines Wohnsitzes im Kanton X unzumutbar wäre, zumal er ja seinen Wohnsitz im ganzen Kanton X frei auswählen darf. Somit steht dem öffentlichen Interesse an einer engen Verbundenheit des Beschwerdeführers mit dem Kanton X kein überwiegendes privates Interesse gegenüber, womit die Auferlegung der*

Wohnsitzpflicht auch als zumutbar erscheint. Ferner gilt es zu beachten, dass A Staatsangestellter in hoher Stellung ist, weshalb im vorliegenden Fall die Zumutbarkeit umso mehr bejaht werden kann.
Fazit: *Die Zumutbarkeit ist gegeben.*

Zwischenergebnis Verhältnismässigkeit*: Die Verhältnismässigkeit der Einschränkung ist im gegebenen Fall zu bejahen.*

Anmerkung: Die gegenteilige Ansicht wird, sofern überzeugend begründet, ebenfalls mit voller Punktzahl bewertet.

d) Schutz des Kerngehalts

Art. 36 Abs. 4 BV
In den Kerngehalt eines Grundrechts darf unter keinen Umständen eingegriffen werden. Ein Freiheitsrecht darf weder völlig unterdrückt noch seines Gehalts als fundamentale Institution der Rechtsordnung entleert werden.
Zum Kerngehalt der Niederlassungsfreiheit ist das Verbot der Zwangsexilierung von Schweizerinnen und Schweizern zu zählen; diese Garantie fällt mit Art. 25 Abs. 1 BV zusammen. Vom Kerngehalt nicht erfasst wird aber die zwangsweise Zuweisung eines Wohn- oder Aufenthaltsortes.
In casu: *Da das betroffene Freiheitsrecht durch die angeordnete Wohnsitzpflicht im Kanton X offensichtlich weder völlig unterdrückt noch seines Gehalts als fundamentale Institution der Rechtsordnung entleert wird, ist der Kerngehalt nicht verletzt.*
Fazit: *Der Kerngehalt der Niederlassungsfreiheit wird gewahrt.*

e) Gesamtergebnis

Die Einschränkung ist zulässig (gerechtfertigt).

Anmerkung: Andere Meinungen/Ergebnisse wurden bei korrekter rechtlicher Argumentation ebenfalls mit voller Punktzahl bewertet.